

1505298-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS. TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO NA FASE INQUISITIVA. UTILIZAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DEVIDO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REINCIDÊNCIA. PENABASE. MAUS ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. DEMAIS VETORES FAVORÁVEIS. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505298-25.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1505298-25.2022.8.26.0228

Controle nº 288/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GALVÃO GOMES e outro

Aos 24/05/22, às 16 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, os réus LEONARDO GALVÃO GOMES e MARCELO ANTÔNIO VIANA MARQUES (presos no CDP de Pinheiros I), e os seus defensores, respectivamente, Dra. Paloma Rodrigues Vieira Pedroza e Dr. Ellerson Sebastião Costa Martins (réu Leonardo), e Dra. Juliana Mamede Wiering de Barros, Defensora Pública (réu Marcelo). Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas a vítima Adão e as testemunhas Walmir e Fabiano. Os réus foram interrogados. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que as provas produzidas durante a instrução criminal corroboraram por completo a acusação contida na inicial acusatória. De fato, a vítima reconheceu o réu com certeza como sendo o autor do delito. Ao ser ouvido em Juízo afirmou que estava fazendo entregas quando então foi abordada por um indivíduo armado enquanto estava parado no tráfego. Entrou no veículo e mandou que seguisse até um morro, onde em cima do morro o réu Leonardo os esperava. Leonardo subtraiu sua carteira e celular, bem como o veículo, e o levou embora. Foi então levado a um matagal pelo primeiro

assaltante, tendo chegado um terceiro, que o agrediu. Ficou sendo vigiado pelo primeiro assaltante no meio do matagal, até cerca das 10 horas da manhã, quando os policiais vieram resgatá-lo. Tinha sido abordado cerca de 7 horas da manhã. Outrossim, os policiais ouvidos nesta data afirmaram que foram acionados via Copom acerca de um roubo mediante sequestro. Foram até o local indicado e ali chegando encontraram dois indivíduos – depois identificados como os réus – descarregando a carga de um veículo para dentro de um barraco. Os acusados fugiram para dentro do barraco, onde foram detidos. Dentro do local já havia mercadoria descarregada. A vítima não estava dentro do barraco, estava sendo mantida em cativeiro em outro local. Os réus, quando interrogados, negaram a prática do delito, apresentando versões que não encontram respaldo nos elementos de prova trazidos aos autos. No entanto, admitiram que transferiram a carga do veículo para o barraco, sabendo que esta era roubada. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que LEONARDO GALVÃO GOMES e MARCELO ANTONIO VIANA MARQUES seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se pena base em seu mínimo legal, pois são primários, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. Pela defesa do réu Marcelo foi alegado, em síntese: MM Juiz, a denúncia imputou aos réus o cometimento da conduta prevista no 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, uma vez que, em tese, os réus teriam realizado um roubo de carga e itens pessoais do motorista do caminhão. A defesa requer, pelos fundamentos a seguir deduzidos, a improcedência da pretensão condenatória. A vítima, em audiência e mediante perfilhamento, reconheceu apenas o réu Leonardo. Mesmo em sede policial, ocasião em que apenas os dois acusados foram apresentados para o reconhecimento de pessoas, a vítima não reconheceu Marcelo, por não ter este réu participado do roubo. Já os policiais informaram que prenderam em flagrante os dois réus perto do barraco em que era realizada a descarga do carro subtraído. No local dos fatos, contudo, não existia qualquer arma de fogo, razão pela qual não houve a apreensão e perícia do instrumento. A vítima, por sua vez, não foi levada ao referido barraco, tendo sido largada pelos roubadores em um matagal, enquanto o carro foi levado para o referido barraco. Leonardo, em interrogatório, confirmou ter chamado Marcelo para auxiliá-lo no descarregamento de uma carga de propriedade do amigo Costela, já que Marcelo residia próximo ao local dos fatos e receberia um dinheiro com este serviço. De igual forma, Leonardo informou que Marcelo ficou no barraco aguardando o carro para realizar a descarga, sem ter participado do crime de roubo ou sequer encontrado a vítima e Costela. Marcelo, em interrogatório, apresentou a mesma versão de Leonardo. Dessa forma, e seguindo a dinâmica dos fatos narrada por todas as testemunhas, o réu Marcelo deve ter desclassificado o crime de roubo para o de favorecimento real previsto no artigo 349 do CP, uma vez que não tinha ciência de que seria realizado um crime de roubo, aceitando a oferta apenas de descarregar um carro em troca de um dinheiro. As provas nos autos demonstram que a vítima não viu o réu, de modo que ficou evidente que este não participou do roubo. Marcelo também não tinha contato com os demais corréus, conhecendo apenas Leonardo e aceitando a oferta feita por este. Assim, deve ser reconhecida a participação dolosamente distinta prevista no artigo 29, §2º, do CP. Na hipótese de decisão condenatória, passa a defesa a formular os seguintes pedidos subsidiários: (a) requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, haja vista as circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis ou inerentes ao tipo penal infringido, devendo ser ressaltado o disposto na súmula 444 do STJ; (b) Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade do réu MARCELO, prevista no artigo 65, inciso I, do CP. De igual modo, sendo considerado pelo Juízo que a conduta do réu consistiu em divisão de tarefas dentro do crime de roubo, sendo este corréu, deve ser reconhecida a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso II, d, do CP, eis que Marcelo confirmou estar no local dos fatos e ter auxiliado na descarga do material (súmula 545 do STJ); (c) No que tange à terceira fase, requer o afastamento da majorante da arma de fogo do crime de roubo, já que não foi apreendida nem periciado o referido instrumento, de modo que não é possível atestar se possuía potencial lesivo. Requer, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do CP, para que seja atenuada a pena deste réu que apenas

participou da descarga de material. Pugna, por fim, pela fixação do semiaberto para o início do cumprimento de pena, considerando o que dispõe o art. 33, §2º, 'b', do Código Penal e o fato de o réu ser primário e possuir bons antecedentes. Postula, ainda, seja concedida a GRATUIDADE DE JUSTIÇA, tendo em vista tratar-se de acusado hipossuficiente. Por fim, requer-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, já que não estão presentes no caso os requisitos da cautelaridade. É O QUE SE REQUER. Pela defesa do réu Leonardo foi alegado, em síntese: LEONARDO GALVÃO GOMES, já devidamente qualificado nos autos supra vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de suas advogadas devidamente constituídas, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS nos termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, pelos fundamentos de fato e de direito nos termos que se seguem. I. O HISTÓRICO PROCESSUAL O acusado foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Após o recebimento da denúncia, o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Regularmente processado o feito e finda a instrução, foi aberto prazo para oferecimento de memoriais escritos, sendo que, após manifestação ministerial, os autos vêm à defesa, que passa a postular. II. DO DIREITO II.A - DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO. DA ABSOLVIÇÃO Em observância às provas constantes dos autos, não há que se falar na ocorrência de dois roubos em concurso formal, mas apenas um, eis que as subtrações foram realizadas num mesmo contexto fático. Por contexto fático entende-se por mesmo local, tempo e modo de execução. E foi assim que se realizou o crime perpetrado pelo acusado. Excelência, conforme se auferir pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, restou claramente demonstrado que o réu, Leonardo, JAMAIS teve a intenção de subtrair os pertences pessoais da vítima. Malgrado tenha consciência dos fatos somente ao chegar no local, a intenção do réu era de apesara dirigir o veículo e ajudar a descarregar a mercadoria. Mediante ao que se verifica pelos depoimentos, ao chegar para descarregar a mercadoria, Leonardo se deparou com os pertences da vítima no banco do passageiro. Neste momento, o seu comparsa vulgo "Costela" levou o celular às mãos do Sr. Adão, solicitando que o mesmo desligasse o aparelho. Após, colocou o celular dentro do veículo, tendo o Leonardo dirigido o caminhão até o barraco. Ainda, fora informado à vítima pelo seu comparsa vulgo "Costela" que seus pertences pessoais, bem como o veículo, seriam devolvidos assim que terminassem de descarregar a mercadoria. Ainda, o próprio policial militar não relata a apreensão dos objetos junto aos réus. Neste ponto, Excelência, verifica-se completa ausência de dolo quanto à subtração dos bens pessoais, bem como o veículo, de propriedade da vítima, não podendo, portanto, se falar em concurso formal de crimes. O único intuito do réu foi descarregar A MERCADORIA, não desejando, portanto, ter posse de quaisquer outros objetos. Guilherme Nucci nos ensina que, para configurar crime de roubo, deve existir o elemento subjetivo: "Exige-se o elemento subjetivo específico, consistente em subtrair para si ou para outrem". 1 Neste diapasão, ante os elementos colhidos, não se vislumbra a intenção do réu em subtrair os objetos pessoais da vítima, limitando sua atuação somente em relação à carga presente no veículo. A jurisprudência segue harmônica com a doutrina: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ARSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, ainda que esta substancialmente nos depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, é de rigor a manutenção da condenação. 2. Tratando-se de imputação exclusiva de delitos de roubo, impossível o reconhecimento do concurso formal de delitos quando não houver comprovação de que o patrimônio de mais de uma vítima tenha sido efetivamente lesado. 3. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime. Tribunal de Justiça de Pernambuco TJ-PE - Apelação: APL 0017923-47.2007.8.17.0001PE Ainda, vale ressaltar que o concurso formal somente se incidiria se houvesse lesão à múltiplos bens jurídicos, embora com uma única conduta do réu, fato este que não ocorreu. Assim: Roubo majorado pelo concurso de pessoas. 1. Conjunto probatório fornece certeza

quanto à autoria e materialidade delitivas. 2. Depoimentos das vítimas e testemunha, que foram prestados com lógica e coerência, deve receber crédito do julgador. 3. Comprovada a causa de aumento atinente ao emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Arma apreendida por força da prisão em flagrante do réu em decorrência de outro roubo e reconhecida pelas vítimas do roubo destes autos. Arma periciada e constada a potencialidade lesiva. 4. Prova emprestada. Admissibilidade. Prova produzida em processo em que o réu é parte. Respeitados o contraditório e ampla defesa. 5. Demonstrada a prática da infração penal em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, impõe-se a aplicação da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). 6. A pluralidade de vítimas, no contexto de uma só ação, sem interrupção de tempo e de lugar, caracteriza crime único, e não concurso formal de crimes. 7. Fixação do regime inicial fechado, tendo em vista que o réu cometeu o crime quando estava foragido da Justiça. 8. Reprimenda reduzida. Pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00020373520118260189 SP 0002037-35.2011.8.26.0189, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 27/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/01/2015). Grifos não originais. Cumpre ressaltar que não há provas robustas nos autos capazes de assegurar a conduta dolosa do réu quanto à subtração de múltiplos bens, motivo pelo qual deve ser o caso analisado sob o prisma do in dubio pro reo. A condenação exige certeza. A prova deve ser indiscutível e trazer segurança ao magistrado para afastar a inocência de um acusado. [...] As provas constituem os olhos do processo, o alicerce sobre o qual se ergue toda a dialética processual. Sem provas idôneas e válidas, de nada adianta desenvolverem-se aprofundados debates doutrinários e variadas vertentes jurisprudenciais sobre temas jurídicos, pois a discussão não terá objeto. A prova constitui elemento imprescindível na condenação de um cidadão. A ausência de provas afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório e, substancialmente, do princípio da inocência. Provar, é antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade; e as provas são os meios pelos quais se procura estabelecê-la. É demonstrar a veracidade do que se afirma, do que se alega. Nesta esteira, ante a ausência de provas claras, concretas, confiáveis quanto ao dolo do réu, Leandro, requer a absolvição de denúncia por um crime roubo, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. III. DA DOSIMETRIA DA PENA. III. A- DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA Verifica-se que o réu confessou a prática do delito em sede policial, bem como em juízo. Assim, requer o reconhecimento da confissão como atenuante (art. 65, III, d, CP), vez que a jurisprudência do C. STJ está consolidada no sentido de que a confissão, uma vez empregada para fundamentar a decisão, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, ainda que parcial ou apenas na fase de inquérito. A propósito: GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSTULAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADES FLAGRANTES CONSTATADAS. CORREÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PRÓPRIA (ART. 654, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS. TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO NA FASE INQUISITIVA. UTILIZAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DEVIDO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REINCIDÊNCIA. PENABASE. MAUS ANTECEDENTES. UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. DEMAIS VETORES FAVORÁVEIS. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO). DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 5. A confissão do Agravante de que exercia a traficância, efetivada na fase policial, foi utilizada para fundamentar a condenação. Portanto, ainda que tenha sido retratada em juízo, faz ele jus à atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior. [...] 7. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para aplicar a atenuante da confissão e compensá-la, integralmente, com a

reincidência, bem assim reconhecer a desproporcionalidade e diminuir o quantum de aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (AgRg no AREsp 1795241/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/04/2021). Outrossim, conforme o auto de qualificação anexado às fls.31, verifica-se que o acusado tinha 18 anos na data dos fatos. Assim, correto será o reconhecimento também da atenuante da menoridade relativa, conforme art. 65, I, do CP. III – B. DA ATENUANTE POR CONFISSÃO. Destarte caloroso debate em juízo, o réu confessou sim sua participação no crime de roubo. Relata que quando recebeu a ligação para descarregar a carga não sabia do que se tratava, tomou conhecimento dos fatos ao chegar no local que viu o motorista, aceitou dirigir o veículo e, portanto, assumir responsabilidade na função do crime. Sendo assim, conforme expressa situação descrita, requer seja considerado a confissão do réu. III – C. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO Da análise dos autos, verifica-se que as majorante referente ao uso de arma de fogo não restou plenamente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual. Para a aplicação de tal qualificadora não se faz necessária a apreensão da arma. Mas, é necessário que os relatos, ou mesmo outros meios de prova, corroborem com versão da vítima quanto ao uso do instrumento bélico. Vejamos o posicionamento da doutrina sobre o tema: “[...] a maioria da jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ) orienta que, para a configuração da majorante, mostra-se dispensável a apreensão da arma utilizada no crime, desde que sua utilização fique demonstrada por outros meios de prova” Ocorre que, no caso em tela, a discussão se torna ainda pior e mais complexa. Sem a apreensão e subsequente perícia do instrumento, é impossível o reconhecimento da majorante em questão. Primeiro, porque torna incerta a sua utilização para o crime e, segundo, porque inviabiliza a averiguação de sua capacidade vulnerante. Neste sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP). Réu que, acompanhado de outros agentes, teriam subtraído, com emprego de arma de fogo, 238 telefones celulares e 6 tabletes de estabelecimento comercial. Sentença condenatória. Irresignação da acusação e do réu. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Condenação que se funda notadamente nas imagens das câmeras da empresa vítima, confirmatória pelo envolvimento do réu no delito. Dosimetria. Circunstâncias fáticas que exigem efetivamente uma penabase acima do mínimo legal. Manutenção da atenuante da confissão extrajudicial. Afastamento somente da causa de aumento do emprego de arma de fogo, por ausência de provas, sem repercussão da pena, cujo aumento se deu em 1/3. Recurso da acusação desprovido e recurso da defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0007349-85.2016.8.26.0554; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2022; Data de Registro: 07/05/2022) No mais, ainda que se torne como fidedigno e acurado o depoimento da vítima, que afirma ter o comparsa do acusado utilizado arma de fogo para cometer o delito em questão, não há como saber se aquilo que ela efetivamente viu era simulação de arma de fogo, arma de brinquedo, arma desmuniada ou mesmo arma disfuncional. Assim, sem prova concreta e efetiva da potencialidade lesiva do suposto instrumento avistado pela vítima, não há que se falar na aplicação dessa majorante. Cabe ressaltar que a incidência da causa de aumento de pena tem como fundamento a existência de maior grau de lesividade na conduta do agente armado. É dizer, há exasperação de pena somente nas hipóteses em que há real incremento do risco à vida, à integridade física e ao patrimônio do ofendido em razão do emprego da arma de fogo. Tal orientação mantém

exata coerência com cancelamento da Súmula 174 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao afastar justificativa de ordem subjetiva consistente no potencial intimidativo da imagem de uma arma de fogo. Ante todo o exposto, requer-se o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Caso se entenda pela incidência da causa de aumento de pena referente à arma de fogo, requer seja aplicado aumento mínimo, pois não é apenas o número de causas de aumento que justifica a aplicação de fração maior, conforme, inclusive, entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 443). IV. DA FIXAÇÃO DA PENA BASE E DO REGIME DIVERSO DO FECHADO A culpabilidade, como princípio

medidor de pena, somente poderá ser considerada de forma desfavorável ao réu quando houver circunstâncias fáticas específicas que não sejam inerentes ao tipo e que tornem o crime, no caso concreto, dotado de especial reprovabilidade. No entanto, temos que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Além disso, as circunstâncias do artigo 59 do CP são favoráveis, o réu Leonardo não é reincidente, e não tem personalidade voltada para a criminalidade. Por estes motivos elencados, a resposta punitiva, há de ser proporcional aos contornos do fato delituoso que se afirma. Assim, requer que a pena base seja fixada no mínimo legal. Quanto ao regime de pena, verificando a situação do Acusado, é possível concluir que este possui residência fixa no Distrito da culpa, não se dedica a atividades criminosas, muito menos integra organização criminosa, não demonstrou personalidade agressiva e cooperou com a justiça confessando o delito. Verifica-se que este M. juízo tem reservado o fechado, para crimes de roubo, quando cometidos com emprego de arma. No caso, não restou comprovado a utilização de emprego de arma de fogo. Sendo assim, é plenamente possível a aplicação do regime semiaberto, até porque a grave ameaça integra o tipo penal. Pode-se dizer, assim, que o dolo na espécie foi o normal. Ademais, cumpre ressaltar que é vedado ao julgador, no crime de roubo, utilizar de fundamentação genérica para a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo do que dispõe a lei como, por exemplo, a "gravidade abstrata do delito" ou a possível "descrença nas instituições públicas". Nesse sentido, inclusive, dispõe as Súmulas nº 718 e 719 do C. Supremo Tribunal Federal e nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça: STF - Súmula nº 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. STF - Súmula nº 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. STJ - Súmula 440. Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Eventual entendimento no sentido da fixação de regime mais rigoroso importa, com o devido respeito, em ignorar a dogmática jurídica e ater-se aos valores do próprio julgador, que não podem se sobrepor aos da lei. Confirma-se orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Agravado Regimental no Habeas Corpus. Roubo. Regime inicial fechado determinado com base na gravidade em abstrato do delito. Descabimento. Penabase fixada no mínimo legal. Circunstâncias do caso concreto. Artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Súmula 440 deste STJ, 718 e 719 da Suprema Corte. Constrangimento ilegal evidenciado. Fixação do modo semiaberto. Ordem concedida de ofício. Decisão monocrática confirmada. Agravado improvido. 1 - O art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, estabelece que o condenado à pena superior a 4 anos e não excedente a 8 poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal. 2 - A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou entendimento no sentido de que a opinião do julgador acerca da gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento mais gravoso do sentenciado, orientação que é acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 440. 3 - Na hipótese, diante da ausência de fundamentação concreta para a imposição do sistema prisional fechado e estabelecida a pena-base no mínimo legal, com consideração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, evidente o constrangimento ilegal a que estava submetido o acusado, dando ensejo à concessão da ordem mandamental para fixação do regime inicial semiaberto. 4 - Ressalte-se que o fato de ter sido cometido o delito em desfavor de duas vítimas, o emprego de golpes no estômago de uma delas, além das avarias ocasionadas no veículo furtado pela batida durante a fuga, são circunstâncias que não se mostraram suficientes para, no caso concreto, justificar o agravamento da reprimenda corporal, tratando-se de fundamentação baseada em elementos do próprio tipo penal, de modo que também não poderiam ser utilizadas para agravar o modo de cumprimento da pena. 5 - Agravado Regimental improvido." (Ag Rg no HC 430.266/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE 30/08/2018). Deste modo, pelas circunstâncias e natureza do delito, pela personalidade e idade do acusado, requer a aplicação de um regime mais brando,

sendo fixado o regime semiaberto. IV. – DOS REQUERIMENTOS Sendo assim, considerando as razões acima deduzidas, requer a Defesa o que segue: A) Pena base no mínimo legal; B) Reconhecimento da atenuante da Confissão e atenuante da Menoridade Relativa; C) Afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo; D) Reconhecimento de crime único de roubo; E) Regime mais brando, semiaberto. Nestes termos, pede e espera deferimento. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LEONARDO GALVÃO GOMES e MARCELO ANTÔNIO VIANA MARQUES, qualificados nos autos, estão sendo processados porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso entre si e com outros dois indivíduos ainda não identificados, todos atuando com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Adão Barbosa dos Santos, o veículo automotor Fiat/Fiorino Endurance, de placas GFM6D97, com a respectiva carga, consistente em 112 (cento e doze) caixas contendo gêneros alimentícios diversos das marcas Perdigão e Sadia, de propriedade da empresa Canuto Filho Rotisserie e Distribuidora, além do celular iPhone 6s, celular Asus e carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, todos da vítima Adão Barbosa dos Santos. Os réus foram presos em flagrante. Citados, apresentaram defesas escritas, devidamente apreciadas. Na instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas na denúncia. Os réus foram então interrogados. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, enquanto as defesas pediram a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios postos neste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, no tocante aos roubos, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que os réus são dois dos roubadores. Em seu interrogatório judicial, o réu Leonardo primeiramente negou a autoria do roubo. Disse que estava em casa e recebeu ligação de um tal “Costela”, sendo convidado para descarregar produtos. Foi ao local com Marcelo, pois precisavam de mais de uma pessoa para descarregar. Disse que não sabia que a carga era roubada. Viu o motorista do veículo e um indivíduo pegando o celular e carteira dele, mas dizendo que estava tudo certo e que iria devolver depois. Tomou a direção do veículo e levou o carro ao barraco onde foi preso depois. Nada tem contra as testemunhas e já foi preso por roubo quando menor inimputável. Ao ser questionado por seu defensor constituído, alterou e disse que confessa envolvimento no roubo, e já sabia que se tratava de assalto quando descarregava os produtos. Marcelo negou envolvimento no roubo. Disse que foi chamado a descarregar e não sabia que a carga era roubada. Nada confessou aos policiais e nada tem contra eles. Quando menor inimputável já foi preso por receptação e roubo. Na fase policial, Leonardo iniciou já confessando amplamente a autoria do roubo, dizendo que com o corréu Marcelo e mais indivíduos, decidiram praticar o assalto, subtraindo uma Fiorino com a carga. Ficou com Marcelo para descarregar o veículo, momento em que os policiais chegaram. A vítima havia ficado sob custódia dos outros assaltantes. Disse que saiu da Fundação Casa por conta de roubo há três meses. Marcelo, na fase policial, repetiu que não tem envolvimento no roubo e que apenas foi chamado para descarregar o veículo. Contou que há quatro meses saiu de internação por ato infracional equivalente a roubo. A denúncia procede claramente. A vítima, em juízo, reconheceu o réu Leonardo, com certeza, como sendo um dos autores do roubo, estando ele perfilhado com demais indivíduos. Explicou que reconheceu Leonardo também na fase policial. Explicou ainda que não viu as fisionomias dos demais assaltantes, e não pode reconhecer o corréu Marcelo, e já não o tinha reconhecido na fase policial. Contou que fazia entregas e foi abordado por um assaltante, com arma de fogo, que anunciou assalto e levou o declarante e o carro roubado ao morro, sob ameaça. Não viu a fisionomia desse indivíduo,

que estava de máscara e chapéu. Já no morro, viu Leonardo, que pegou seus pertences pessoais e o carro, estando ele com o rosto desnudo. Foi levado por terceiro para um matagal. Havia pelo menos mais um assaltante além dos réus. Foi

agredido com rasteira. Soube que quando descarregavam os produtos do veículo, a polícia chegou. Duas pessoas foram presas, uma delas Leonardo. Soube que o outro preso estava descarregando os produtos também. Ficou em um barraco no matagal. Restou em poder dos assaltantes por mais de duas horas. Levaram seu celular, que estava no carro, e sua carteira, que estava em seu bolso. A testemunha Walmir disse ter sido acionada pelo COPOM, em razão de roubo mediante sequestro. No local, viram dois indivíduos descarregando caminhão. Correram ao ver a polícia, para um barraco, onde parte da carga roubada já se encontrava. Anotou ter certeza de que ambos os réus lhe confessaram que praticaram o roubo. A vítima ficou privada de liberdade por mais de uma hora, pelo que soube, mantida em cárcere. Não apreendeu arma de fogo. Fabiano disse também que os dois réus foram presos próximos do veículo roubado, não se lembrando se confessaram envolvimento no roubo. Não encontrou arma. Foram apreendidos celular e carteira da vítima. Vinga mesmo a ação penal. O réu Leonardo acabou confessando envolvimento no roubo, em juízo. Já havia confessado no auto do flagrante. Foi reconhecido com certeza pela vítima como um dos assaltantes, na fase judicial, assim como na administrativa. Foi encontrado com o produto do roubo, descarregando esse produto do carro para o barraco ao qual fugiu ao ver a polícia. Confirmou também que chegou a guiar o carro roubado até o local em que foi descarregado. Também vinga a ação de modo claro em relação a Marcelo. Embora não reconhecido, tendo a vítima explicado esse motivo, ou seja, que não viu o rosto dos demais assaltantes, mas apenas de Leonardo, tanto assim que o ofendido, de modo convergente, não reconheceu Marcelo em ambas as fases do feito, o fato é que o restante da prova é muitíssimo suficiente para comprovar sua responsabilidade. Desde o início já disse Leonardo, em seu interrogatório no auto do flagrante, que um dos assaltantes, além dele próprio, era o corréu Marcelo. Demais disso, Marcelo foi preso quando visto descarregando os produtos do veículo roubado, e fugindo da polícia a partir de tal veículo para um barraco, onde já se encontrava parte da carga subtraída. Mais ainda, Marcelo confessou às testemunhas ouvidas no processo seu envolvimento no roubo, e é dos autos que ambos os imputados efetivamente estavam na posse da carga produto do roubo. Walmir ratifica isso em juízo e ambas as testemunhas falaram dessa confissão de ambos os réus e do descarregamento conjunto por eles, no auto do flagrante. As testemunhas também, quando ouvidas no dia da prisão dos réus, ratificaram que com Leonardo, preso junto com Marcelo, estavam pertences pessoais da vítima, como celular e carteira, estando essa vítima ainda privada de liberdade. Assim, evidentemente está bem delineado o dolo no tocante aos roubos, não havendo de se falar em participação de menor importância ou na intenção inicial de participar de crime menos grave, eis que desde o início sabiam do roubo e dele participaram plenamente. Os roubos se consumaram. Ocorreu plena inversão da posse dos bens roubados, sendo completadas a grave ameaça e a violência, circunstâncias bastantes para a consumação do delito, aliás como vem entendendo as Cortes Superiores. Vinga a qualificadora do concurso de pessoas, pois bem demonstrada pela prova obtida nos autos. Eram ao menos três ou quatro os roubadores e a prova é suficiente nesse sentido, sendo que a participação de todos foi relevante para a consumação das infrações penais. Vinga ainda a qualificadora da restrição de liberdade, eis que a prova é no sentido de que a vítima teve sua liberdade restringida, forçadamente, por cerca de duas horas ao menos, sob cárcere em barraco, tempo muito mais do que o que seria suficiente para a consumação da subtração. Não vinga a qualificadora do emprego de arma de fogo, eis que armamento algum foi apreendido para se aquilatar sua potencialidade lesiva. Com uma ação praticaram os réus dois delitos de roubo, com resultados autônomos, invadindo patrimônios distintos, e de todo cientes de que essa invasão era mesmo de patrimônios diferentes, como bem indicou a prova dos autos, sendo o veículo e a carga da empresa subtraídos de um lado, e bens pessoais da vítima Adão, como sua carteira, que estava em seu bolso, de outro. Caracterizado, assim, o concurso formal de delitos. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, deve a sanção base para o delito de roubo ser fixada um ano acima do mínimo de lei, tal porque se trata de roubo mais grave do que o padrão para a espécie, havendo subtração de carga, além da firme notícia de porte de arma durante o assalto (a sua não apreensão impede a qualificadora pertinente, mas não a



exasperação de pena pela maior gravidade da ação e maior desvalor da conduta). As penas são postas, portanto, em cinco anos de reclusão e doze dias multa. Na segunda fase de fixação de reprimenda, reduzo as penas de três meses para o réu Marcelo, em razão da atenuante da menoridade relativa, e de seis meses para o réu Leonardo, em razão da menoridade relativa e também da confissão, sendo as penas ora fixadas, para Marcelo, em quatro anos e nove meses de reclusão e onze dias multa, e para Leonardo, em quatro anos e seis meses de reclusão e onze dias multa. Anoto que há notícia nos autos de que foram livrados de internação por ato infracional equivalentes a roubos muito pouco tempo antes da prisão em flagrante do presente caso, o que, entretanto, ora não altera a pena em razão de não se tratar de efetivo antecedente criminal, e não forjar reincidência. Na terceira fase, a sanção do roubo deve ser aumentada de dois quintos, em razão da dupla majorante (concurso de pessoas e restrição de liberdade), notando-se que a presença das duas qualificadoras, mormente no caso em tela, indica maior desvalor da conduta, demonstrando que não se pode apenar igualmente um delito majorado por uma causa especial de aumento de pena e outro com dupla majorante, com sanção, para Marcelo, de seis anos, sete meses e vinte e quatro dias de reclusão e quinze dias multa, e para Leonardo, de seis anos, três meses e dezoito dias de reclusão e quinze dias multa. Por fim, aumento a sanção de um sexto, pelo concurso formal de crimes, com pena final, para Marcelo, de sete anos, nove meses e três dias de reclusão e dezenove dias multa, e para Leonardo, de sete anos, quatro meses e seis dias de reclusão e dezoito dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, os réus LEONARDO GALVÃO GOMES e MARCELO ANTÔNIO VIANA MARQUES, qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V (afastados o §2º-A, inciso I), por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprirem, MARCELO, as penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias multa no valor unitário mínimo legal, e LEONARDO, as penas de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciarão os réus cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, eis que o delito é considerado hediondo, nos termos da lei nº 8.072/90, com a redação da lei 13.964/19, tudo ainda em razão da gravidade intrínseca dos delitos, desassossegadores da sociedade, sendo o regime fechado o único que se coaduna com roubo duplamente qualificado que inclui a restrição de liberdade e a subtração de carga, indicando ousadia dos agentes. Não poderão os réus recorrer em liberdade, pelos mesmos motivos. Expeçam-se mandados de prisão pela sentença condenatória ou recomendem-se os réus onde se encontram recolhidos. Expeçam-se guias de recolhimento provisórias ou definitivas, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e as Defesas técnicas se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como os réus, já sido dispensados da presença no fórum, em razão do adiantado da hora (18 horas). Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, Escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES